

1500268-92.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

...

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500268-92.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-92.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO DE CASTRO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

MARCOS ROBERTO DE CASTRO SOUZA, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 26 de janeiro de 2021, por volta de 15h, na Rua Benedito Pereira Batista, 40, Jd. Vanessa, neste município e Comarca de Mairiporã, o réu, teria trazido consigo para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções de maconha, 13 (treze) porções de cocaína e 12 (doze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 08; laudo de constatação preliminar de fls. 10/15 e exame químico-toxicológico de fls. 48/50. Consta na denúncia (fls.61/63), que, segundo o apurado, o réu, hipoteticamente, determinado a praticar o delito de tráfico de drogas, providenciou os entorpecentes e os colocou dentro de uma sacola plástica preta. Em seguida, teria rumado para o local dos fatos, já conhecido como de intensa traficância, a fim de encontrar consumidores e comercializar o entorpecente. Conforme o alegado, Policiais Militares patrulhavam o local, quando, teoricamente, visualizaram o réu saindo de um terreno baldio, situação em que carregava uma sacola preta nas mãos. Na sequência, ao avistar a viatura policial, o réu, em tese, tentou se evadir por um matagal, mas foi alcançado. Abordado, no interior da sacola plástica que o réu carregava, supostamente, foram encontrados os entorpecentes apreendidos, além de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, proveniente do

comércio ilícito.

O réu foi preso em flagrante delito às fls. 01.

Em solo policial, o réu confessou estar traficando no local (fls. 04).

O Ministério Público requereu às fls.28/29 que seja a prisão em flagrante convertida em preventiva, pois presentes seus requisitos, fundamentos (artigo 312, do Código de Processo Penal) e condições de admissibilidade (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

A Defensoria Pública manifestou-se às fls. 34/35, anotando que, não resta demonstrada a imprescindibilidade da prisão cautelar, tratando-se de crime de perigo abstrato, autuado primário e com endereço fixo, pugnou-se a concessão de Liberdade Provisória com a imposição de algumas das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura. Decisão às fls. 36/39 em que concedeu liberdade provisória ao réu, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, impondo-lhe as medidas cautelares seguintes: a) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 10 (dez) dias sem comunicar o juízo; e b) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h) e nos dias de folga. Não obstante, foi determinada a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Alvará de Soltura às fls. 40/42.

Decisão às fls.65/66 em que determinou que proceda-se à notificação do denunciado.

O Ministério Público às fls.78, conforme fls. 75 e diante do descumprimento da medida cautelar imposta, e com base no artigo 282, §4º e 312, §1º, do Código de Processo Penal, requereu que seja decretada a prisão preventiva do réu, expedindo-se o mandado de prisão.

Decisão às fls. 80/81 em que decretou a prisão preventiva do réu, posto que descumpriu as obrigações que lhe cabiam e, assim, impediu a persecução penal, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Mandado de Prisão às fls.94/95.

Regularmente notificado (fls.99), o réu, por intermédio de defensora dativa, apresentou defesa prévia às fls. 103/105, pugnando que ao final seja absolvido, haja visto todas as circunstâncias que lhe são amplamente favoráveis; quanto ao mérito, reserva-se para fazer alegações na fase dos Memoriais Finais; por fim, arrolou as mesmas testemunhas do órgão acusador.

O representante ministerial às fls. 110/111 requereu o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

Recebida a denúncia às fls. 114/115, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 139/140), foi ouvida a testemunha Johnny Willames e, em seguida, designado audiência em continuação e mantido o decreto prisional do réu.

Em audiência de instrução e julgamento, em continuação (fls.154/155), foi ouvida a testemunha Diego Luiz Nicochelli e, posteriormente, interrogado o acusado.

Em memoriais orais, a d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ante a natureza nociva de duas das drogas apreendidas, quais sejam, cocaína e crack; na segunda fase, presente a agravante do crime ter sido cometido durante estado de calamidade pública, diante da pandemia da Covid-19 e a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou diminuição, afastando o privilégio do artigo 33, §4º, da LD, pois foi encontrado com grande variedade de drogas e em quantidade considerável, bem como informou ter sido condenado pelo mesmo crime e que se dedicava ao tráfico para pagar a sua própria dívida. No que tange ao regime, o inicial fechado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A d. defesa, por sua vez, pugnou que o réu seja absolvido por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, anotando que a confissão do réu não é prova plena. Subsidiariamente, que seja a pena-base fixada no patamar mínimo; na segunda fase, reconhecida a confissão; na terceira fase, observou cabível a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da LD, no patamar

máximo. No que toca ao regime, o inicial menos gravoso, reconhecendo a primariedade do agente à época dos fatos, podendo, portanto, recorrer em liberdade. Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 20 e 74, e Folha de Antecedentes às fls. 21/22.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.01), Termo de Depoimento (fls. 02/03), Termo de Interrogatório (fls. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (cocaína - peso líquido 5,65g e 1,07g e Tetrahydrocannabinol - peso líquido 61,12g - fls. 10/15), Nota de Culpa (fls. 16), Depósito Judicial (fls. 54), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (cocaína e Tetrahydrocannabinol - fls. 48/50), Laudo Pericial - Constatação de Objeto (fls.51/53), Relatório Final (fls. 58/59), bem como pelas provas orais colhidas. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material "droga", indicado no tipo penal do caso vertente, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (artigo 158, do Código de Processo Penal c.c. artigo 50, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/06 - LD).

Sobreleva notar que tal substância encontra-se expressamente prevista na Portaria 344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (artigo 1º, Sú., da LD).

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; não bastasse, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do delito, e explanou que, no dia dos fatos, estava vendendo drogas; é viciado; estava por volta de 10 ou 15 dias ao redor; vendia para manter o vício; não estava conseguindo trabalhar com reciclagem, devido a dependência química; ficou devendo os traficantes; ficou dois ou três dias vendendo para quitar a sua dívida; não resistiu a prisão; confessou; está arrependido; está tomando medicamentos que diminui o seu vício pela droga; o valor era de R\$ 5,00 a R\$ 10,00; estava com 20 porções de crack, mais uma porção de cocaína e maconha; não era seu os R\$ 49,00, e sim da venda das drogas; nos 15 dias, nem ia para casa por causa da dependência; o traficante é de prenome Wesley; não está utilizando drogas; está usando remédios controlados; foi oferecido para trabalhar para o Wesley de R\$ 100,00 a R\$ 150,00 por dia.

A par disso, a testemunha Johnny Willames, Policial Militar, em juízo, narrou que, o local já é conhecido pelo ponto de tráfico de drogas; existe escola nas proximidades; durante o patrulhamento, visualizaram a presença do indivíduo; ao notar a presença da viatura na via, o denunciado correu para o mato segurando uma sacola; abordaram o réu; verificaram a sacola; localizaram entorpecente e um pouco de dinheiro; seu parceiro que fez a prisão no primeiro momento.

Igualmente, a testemunha Diego Luiz Nicochelli, Policial Militar, declarou que, no dia dos fatos, a equipe estava em patrulhamento pelo local dos fatos; o local é conhecido pela Polícia Militar como ponto de tráfico de drogas; viu o indivíduo saindo do mato com uma sacola; ao ver a viatura, o agente tentou voltar para o matagal, mas foi abordado; foi constatado que dentro da sacola havia entorpecentes; foi dado voz de prisão; o réu não resistiu; o réu confessou que estava na mercancia para levantar dinheiro para ele e sua família; foi levado para a delegacia, momento que foi ratificado a voz de prisão; na sacola havia maconha, crack e cocaína, e por volta de R\$ 50,00 em dinheiro trocado; fez a abordagem primeiramente, seu parceiro era motorista.

Ressalta-se que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que o réu praticou os núcleos "vender", "trazer consigo", "entregar a consumo" e "fornecer drogas" previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de quantidade de droga suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, e já devidamente fracionada para venda, ainda mais porque não comprovou que exercia qualquer atividade remunerada à época dos fatos, donde se vê que sua conduta causou grande dano à saúde pública, além do fortalecimento de organizações paraestatais, violando o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT776/663). Logo, restou consumada a infração delitiva.

Destaca-se ainda que, é necessário que haja nexo de causalidade entre o crime em tela e a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, no que concerne a pandemia da Covid-19, o que não restou demonstrado. Neste sentido, há jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que: "faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19. Assim, não havendo nexo causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente, de rigor o afastamento da agravante em questão, mantendo-se inalterada a reprimenda." (TJSP, Apelação Criminal nº1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. ANDRADE SAMPAIO, 1ª Câmara de Direito Criminal, j.12.02.2021).

Enfrentando a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que "A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito" (HC nº 654255/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 25.05.2021, DJe 07.06.2021).

Por fim, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal e ao disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, observo que diante da natureza distinta entre os entorpecentes e a quantidade da substância em sua posse, exaspero a pena em 1/8. Assim, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

De outro lado, incide a atenuante da confissão, utilizada para a formação do convencimento desta magistrada, imperiosa a incidência do disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e assim, reduz a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e inviável a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da LD, dado que se dedicava ao tráfico para pagar sua dívida decorrente da dependência química, como declarou o agente em juízo; não

bastasse, possui uma condenação por crime de tráfico, ainda não transitada em julgado (autos nº 1501066-53.2021.8.26.0535). Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial será o semiaberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Ante o "quantum" da pena, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, e por tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO DE CASTRO SOUZA à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, caput, e parágrafos, do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal), já que o recolhimento ao cárcere se mostra necessário para resguardar a ordem pública, ante o desassossego social causado pelo crime cometido pelo acusado. Além disso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revela insuficiente para impedir a repetição da conduta delitiva.

Ainda, atendendo a nova redação do artigo 387, § 2º, Código Processual Penal, dada pela Lei 12.736/12, deixo de proceder à detração da pena, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Como a quantia apreendida e o bem apreendido estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva - fruto da mercancia da droga-, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (artigo 72, da LD).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C., Mairiporã, 08 de Fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA